

1527935-04.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527935-04.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527935-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312011/2021 - DEL.SEC.7ª

ITAQUERA, 21419944 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 371/21/070 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 2312011 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON LOURENÇO MOREIRA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

EDSON LOURENÇO MOREIRA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isto porque, no dia 16 de novembro de 2021, no período da manhã, na Rua Rio Imburana, nº 393, Jose Bonifácio, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, vendia e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 32 porções de cocaína, pesando um total de 19,9g, e 42 porções de tetrahydrocannabinol (THC), na forma popularmente conhecida como "maconha", pesando um total de 155,1g, substâncias entorpecentes que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar,

Segundo consta, o denunciado vendia e trazia consigo as drogas acima descritas, a fim de entregá-las ao consumo de terceiros. Ocorre que, policiais civis em diligências, visando a verificar informações que davam conta da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, em procedimento de observação velada, visualizaram o denunciado em atitude característica da venda de entorpecentes. No caso, indivíduos aproximavam-se de acusado, entregavam-lhe algo (dinheiro) e este, em contrapartida, retirava um objeto da bolsa que trazia consigo e passava às mãos do indivíduo (drogas). Os policiais puderam notar que a atitude se repetiu por algumas vezes. Verificada a situação, os policiais aproximaram-se para realizar a abordagem, ocasião em que o denunciado e demais indivíduos que lá estavam tentaram correr. O acusado foi abordado pelos policiais, que, em revista, localizaram no interior da sua bolsa as porções de drogas acima descritas, devidamente embaladas, e o valor de R\$30,00 em dinheiro trocado. Indagado, o denunciado confirmou que estava vendendo drogas, porém se negou a dizer o nome de seu "empregador". Lavrado o auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), o acusado recebeu nota de culpa (fls. 21), foi pregressado (fls. 20) e qualificado (fls. 22). Oferecida a denúncia de fls. 01/03, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 05/84, o acusado foi notificado (fls. 146), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa preliminar de fls. 100/104, subscrita por Dr. Defensor constituído. A denúncia foi recebida por decisão no dia 07 de fevereiro de 2022 (fls. 152/156).

Durante a instrução da causa foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação e duas arroladas pela defesa, sendo o acusado interrogado ao final da instrução.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postula a total procedência da ação penal e seja aplicado o redutor do §º 4 do artigo 33 da Lei 11.343/06, regime aberto. O Dr. Defensor constituído, por seu turno, pugna, pela absolvição de seu assistido, com fulcro no artigo 386, inciso I, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 10/12); o auto de exibição e apreensão (fls. 117/18); o laudo de constatação (fls. 13/16); o laudos do exame químico-toxicológico (fls. 143/145), o laudo da bolsa apreendida (fls. 140/142); as folhas de antecedentes criminais do acusado (fls. 89/90) e as certidões cartorárias de fls. 91 e 129.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e dos laudos de constatação provisória (fls. 13/16), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 143/145), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Júlio, policial civil declarou que reconhece o acusado de um flagrante de tráfico de drogas. Após receber uma denúncia de tráfico de drogas. Características passadas fizeram a campana de 15 a 20 minutos. Chegou a presenciar por umas 3 vezes ele negociar drogas com terceiros. Resolveram fazer a abordagem. O usuário fugiu. O entorpecente estava em uma bolsa no corpo dele. Ele disse que fazia o tráfico por necessidade, desempregado. Não se recorda das duas tatuagens que aparecem no rosto do acusado. Não o conhecia antes dos fatos. O réu tentou fugir mas já estava sendo observado. A bolsa onde se encontra o entorpecente estava junto com o acusado. O local é uma praça, meio que abandonada.

O policial Jacques também reconheceu o acusado. Varias denúncias de tráfico de droga e foram até o local indicado, em um local conhecido como "buraco". O acusado estava em uma viela. Fizeram campana de 30 minutos. Presenciou típicos atos de traficância com umas 3 pessoas. O local era uma viela, que dava em uma comunidade. No outro ponto, uma praça. Ficou na rua que era movimentada. Supõe que estava há uns 150 metros de distância. Não se recorda se alguém tentou fugir. As drogas estavam em uma bolsa junto com ele, pouca quantidade, de entorpecente. Ele justificou que estava desempregado e que estava precisando de dinheiro. Em momento algum.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual nacional e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras, que, assim como as dos demais, têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Com efeito, são uníssonos os depoimentos dos policiais, descrevendo que tinham mandado contra o acusado e que, ao investigarem o local onde o réu reside, encontraram os entorpecentes.

Jaqueline, testemunha arrolada defesa. Não conhece o acusado mas já o viu umas duas ou três vezes, na pracinha. Acha que ele não mora na comunidade. Estava sentada com os filhos quando ele foi preso. Ele estava conversando com com uns meninos e quando a policia chegou ele ficou para trás. Os outros correram. A policia chegou a pé. Estavam sem uniforme acredita que eram da civil. Não sabe o que ele estava fazendo naquele local. Mora em um local conhecido por "buraco". Não sabe informar se ali é local com muito trafico mas já viu trafico ocorrendo no local. Ele estava frequentando o local há uns três dias. Ele ia na parte da manhã. No dia dos fatos, ao sair de casa ele já estava lá e logo em seguida a policia chegou. Viu dois policiais. Ele estava com uma bolsinha. Na verdade a bolsinha estava ao lado dele no chão. Na verdade não sabe se a bolsa era dele ou dos meninos que fugiram. Não sabe se ele é usuário de drogas. Não viu se os policiais abriram a bolsa para ver o que estava dentro. Não conhece Nádia.

A testemunha de defesa Nadia declarou que conhece o acusado de vista. Não sabe se ele mora no local. Costuma vê-lo fumando droga, no período da tarde, depois das 16 hs. Já o viu umas três vezes com um grupo de adolescentes. Não conhece a empresa Origem. Quando os fatos ocorreram chamaram a atenção e ele estava fumando maconha com outros. No dia dos fatos ele levou um "enquadro" e depois foi levado pela policia. Não viu se algo foi encontrado com ele. Os demais fugiram. Trabalha entregando panfleto da gráfica Origem. Não se recorda do endereço do seu trabalho. O nome do chefe é Tadeu, mas não se recorda de seu nome inteiro.

Em juízo, o acusado Edson, sob o crivo do contraditório, disse ter 19 anos de idade. Mora com a mãe. Trabalha entregando folhetos. Não tem filhos. Nunca foi processado anteriormente. Fez as tatuagens fora do presídio. É usuário de drogas e sempre vai a praça usar droga no horário de almoço. Nega que estivesse com a droga. Estava com os amigos, Gustavo, Henrique e João. Foi agredido pelos policiais. Não viu o policial apreendendo a bolsinha. Falou que foi agredido na audiência de custódia. Não foi ao local para comprar entorpecente porque já estava com a droga. Em que pesem as negativas do acusado, estas não merecem ser levadas em conta, isto

porque nada trouxe à colação que afastasse de si a responsabilidade pelo delito de tráfico ora apurado, limitando-se a fazer alegações vagas de que não o teria praticado, sem elementos probatórios que comprovassem tal; ao contrário das narrativas e provas trazidas pelos depoimentos das testemunhas de acusação, que apresentam sequência lógica e coesa.

De fato, o réu limita-se a dizer que é usuário de drogas e sempre vai a praça usar entorpecentes no horário do almoço e que no dia dos fatos não teria ido ao local comprar as drogas porque já estaria com elas na sua posse.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade pública eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua prática. Não há prova de nexo causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui Maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa apenas porque estivesse na posse de 175 gramas de entorpecente, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de Maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se

atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3. Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno EDSON LOURENÇO MOREIRA FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato. Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial

lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 17/18). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA